

1501583-82.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... requereu a desclassificação do crime de tráfico para o crime de posse para consumo. Em relação ao acusado Eric, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de posse para consumo. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena mínimo para o crime prescrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/97; e, para ambos os réus, que seja observada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501583-82.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501583-82.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2273189/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 14486366 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 10849/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2273189 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 10849/20/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2273189/2020 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS IVAIR CANDIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

LUCAS IVAIR CANDIDO e ERIC FERNANDO SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16 da Lei 10.826/03, c.c. artigo 29 do Código Penal, porque estes, conluiados e previamente ajustados para a prática criminosa, no dia 04 de novembro de 2020, por volta de 12h00, na rua Kesayoshi Miyashita nº 813, bairro Jussara, nesta cidade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, droga consistente em 52,54 gramas de

Cannabis Sativa L (maconha), substância entorpecente determinante de dependência psíquica, conforme laudos de exames químico toxicológicos de fls. 128/130, 134/136 e 137/139.

Consta dos autos ainda que, na mesma data, na rua Kesayoshi Miyashita nº 813, bairro Jussara, nesta cidade, possuíam, sem autorização legal ou regulamentar, munição e arma de fogo com numeração de identificação suprimida, conforme laudo de fls.131/133.

Infere-se dos autos que, no dia e hora dos fatos, policiais militares estavam patrulhamento pelo bairro Jussara, quando passaram em frente ao número 813, da rua Kesayoshi Miyashita, local conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas, e avistaram um indivíduo em atitude suspeita ingressando no imóvel e decidiram abordá-lo. Ao ingressarem no referido imóvel, os policiais visualizaram aquele indivíduo que ingressara na casa, que posteriormente foi identificando como sendo o usuário W.A.T. recebendo algo do denunciado Lucas, e a ele entregando algo, em atividade típica de tráfico de drogas.

No local, os policiais avistaram Eric, que correu para dentro da casa e jogou uma sacola ao visualizar a chegada dos policiais. Os policiais apreenderam, em poder de W., 01 porção de maconha. Em poder de Lucas os policiais apreenderam R\$80,00 em dinheiro e 02 porções de maconha embaladas em plástico branco, idênticas àquela encontrada com W. Em poder de Eric nada de ilícito foi encontrado. Na sacola que Eric jogou durante a tentativa de fuga, os policiais encontraram 01 revólver Rossi, calibre 38, com a numeração suprimida, municiado com 02 cartuchos íntegros e 01 porção grande e 03 porções menores de maconha, também embaladas em plástico branco. No interior do imóvel os policiais apreenderam a quantia de R\$1.644,00 em dinheiro. Inquirido pelos policiais, W. informou que acabara de comprar de Lucas a droga encontrada em seu poder, por R\$10,00 a porção. Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito.

Presos em flagrante (fls. 07/14) converteu-se em prisão preventiva em relação ao acusado Eric e concedida liberdade provisória ao acusado Lucas (fls.94/99).

Oferecida a denúncia (fls. 01/02) foram os réus notificados (fls. 163 e 176) e apresentaram defesa preliminar (fls. 164/169), sendo recebida a denúncia (fls. 183/185).

Na instrução foram ouvidas 04 testemunhas (fls. 227/230), sendo que, ao final, foram os acusados interrogados (fls.231/232 e 233/234).

Em sede de memoriais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia, observando-se os maus antecedentes do acusado Eric, e o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União (fls.225/226).

A defesa, por sua vez, em sede de memoriais escritos, em relação ao acusado Lucas, postulou pela absolvição do crime capitulado no artigo 16, da Lei nº 10.826/97, por inexistência de conhecimento da existência da arma e das munições cuja posse e propriedade foi assumida por Eric. Ainda, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o crime de posse para consumo. Em relação ao acusado Eric, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de posse para consumo.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena mínimo para o crime prescrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/97; e, para ambos os réus, que seja observada a atenuante da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição prevista no art.33, §4º, da Lei de Drogas, fixando a pena no mínimo legal. Por fim, postulou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos severo, isenção das custas processuais e direito ao recurso em liberdade (fls. 236/251).

Foi proferida sentença de improcedência a fls. 254/258.

Foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, ao qual fora dado parcial provimento para anular a sentença e para que seja outra proferida, com apreciação do mérito, nos termos do v. acórdão de fls. 321/328.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, encontrando-se pronto o processo, passo ao julgamento do feito, em homenagem à razoável duração do processo e considerando a ausência do Magistrado titular que encerrou a instrução. A esse respeito, confira-se o precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO

DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º)
INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO” (TJSP. Apelação nº 0003826- 11.2012.8.26.0197. Nona Câmara de Direito Criminal. Rel. Roberto Midolla. J. 04.04.2013).

A questão, inclusive, foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada: “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO AO MENCIONADO PRIMADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. 2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 4. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza Substituta Rosaura Marques Borba e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Joni Victória Simões, razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada” (HC 133407/RS, HABEAS CORPUS 2009/0065685-5. Ministro JORGE MUSSI (1138), julgado em 03/02/2011).

No mais, vê-se que a abordagem policial se deu em razão de informações anônimas dando conta que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ademais, na ocasião, os policiais narraram que visualizaram um indivíduo entregar algo ao morador da residência, em movimento suspeito à traficância.

Evidente, portanto, que os policiais tinham fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, na abordagem de pessoa que, em tese, traficava no local. Assim, a prova colhida não está maculada pela invasão de domicílio, diligência que se fez com a guarida da lei e com respaldo no entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.574.681, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, que trouxe as balizas acerca da invasão domiciliar autorizada nos casos de flagrância.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade restou bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, boletim de ocorrência de fls. 16/19, laudo pericial realizado na arma de fogo apreendida (fls. 131/133), bem como pela prova oral colhida. Ainda, a substância apreendida, 52,54 gramas de Cannabis Sativa L (maconha), objeto do laudo de constatação prévia de fls. 50/52, resultou nos laudos de positividade quanto à toxicidade juntados a fls. 128/130, 134/136 e 137/139, revelador de sua natureza entorpecente.

A autoria, de igual modo, é inequívoca.

Em interrogatório, o réu Lucas, nome social “Siara”, negou a autoria dos fatos. Disse que Eric havia ido no mercado, retornando com uma sacola. Nesse momento, escutou alguém entrando. Que estava fumando um baseado no momento da abordagem. Entregou o cigarro e uma outra porção que estava dentro de seu sutiã aos policiais, que revistaram o local. Que na sua bolsa tinha R\$ 1.300,00 todo trocado e na bolsa

de sua mãe mais R\$ 450,00. Tinha um cofre, onde os policiais levaram somente o dinheiro, tendo deixado as moedas. Contou que passava um rapaz na rua, que era seu cliente de luzes, o qual tinha pagado R\$ 15,00 pelo serviço, e ficou de levar R\$ 10,00 na próxima semana. Que os policiais o pegaram pelo colarinho e falavam que ele iria falar tudo aquilo que eles queriam. Viu a sacola verde nos fundos com um revólver em seu interior, além de um pedaço de maconha. Não havia qualquer munição. Que Eric confirmou que conseguiu a arma na rua e que havia escondido na casa. Afirmou que não tinha conhecimento sobre esse revólver.

Em interrogatório, o réu Eric disse que estava chegando do mercado no momento da abordagem. Afirmou que é usuário de drogas e que a porção que foi encontrada era de sua propriedade. Que "um cara" lhe trazia em grande quantidade e tirava em pedaços para consumir. Confirma que a arma apreendida era sua, mas que não tinha qualquer munição.

No entanto, as versões apresentadas pelos acusados não se encontram corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução. A única alegação que se sustenta é referente ao desconhecimento do réu Lucas em relação à apreensão da arma de fogo, cuja propriedade fora integralmente confirmada pelo réu Eric.

Vejamos:

A testemunha Gleiton, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento de rotina pelo local, o qual já era de conhecimento através de denúncias anteriores e de moradores das imediações, se tratar de local de ponto de venda de drogas. Disse que avistou a pessoa de Wanderson abrindo o portão da casa e adentrando no local. Que desembarcou da viatura e ao chegar na residência, cujo portão estava entreaberto, visualizou Wanderson entrando algo para o réu Lucas, o qual devolveu algo ao Wanderson. De imediato houve a abordagem, momento em que visualizou um terceiro indivíduo que tentou se evadir, segurando uma sacola verde nas mãos. Seu companheiro de farda foi ao encalço desse terceiro, posteriormente identificado como Eric, que dispensou a sacola no buraco de um muro que ficava na parede dos fundos. Com Wanderson localizou uma porção de maconha envolta em plástico branco. Indagado, informou que era usuário e que acabara de adquirir a droga de Lucas pelo valor de R\$ 10,00. Lucas segurava em suas mãos uma nota de R\$ 10,00, além de R\$ 70,00 reais em notas trocadas, localizados no seu bolso. Ainda, encontrou em seu poder mais 2 porções de maconha igualmente embaladas àquela encontrada com Wanderson. Contou que Lucas negou a traficância, afirmando que as porções era para seu uso pessoal. No interior da residência, localizou na bolsa de Lucas o valor de R\$ 1.644,00 em notas diversas, o qual não soube informar a procedência. Com Eric nada foi localizado. No entanto, nos fundos, no local em que jogou a sacola, encontrou em seu interior havia um revólver calibre 38 com numeração suprimida, carregado com 02 munições intactas. Havia também uma porção grande de maconha, além de 03 menores idênticas as que estavam com Lucas e Wanderson. Eric assumiu a propriedade da arma e dos entorpecentes.

A testemunha Fernando, policial militar, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda Gleiton, salientando que o local era conhecido como ponto de venda de drogas. Ainda, confirmou que no interior da sacola dispensada por Eric foram encontradas as porções de maconha e a arma de fogo. Afirmou que o réu Eric assumiu a propriedade da sacola.

A testemunha Devanir, mãe do réu Lucas, afirmou que Eric estava em poder de uma sacola do mercado e que os policiais "chegaram quebrando tudo". Disse que Wanderson passava na rua e que os policiais o pegaram pelo colarinho. Que Lucas fuma maconha. Não viu nada de ilícito apreendido.

A testemunha Janaina contou que trabalhava com o réu Lucas e que ele não tem qualquer envolvimento com drogas.

Pois bem.

Em relação ao crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03

Com efeito, o próprio réu Eric confirmou a propriedade da arma de fogo apreendida nos autos, informando que teria adquirido na rua. Por outro lado, não há como comprovar, com a certeza necessária, que o réu Lucas tinha conhecimento dessa circunstância. O fato de residir no local, por si só, não tem o condão de concluir pela sua responsabilidade criminal, sob pena de esta se dar de forma objetiva.

Assim, é o caso de absolver o réu Lucas da imputação de ter praticado o crime previsto no artigo 16 da Lei de Armas.

No que diz respeito ao réu Eric, como já dito, este confessou a propriedade do artefato que, segundo laudo pericial acostado a fls. 131/133, se encontrava com seus mecanismos aptos à realização de disparos, além de estar com a numeração suprimida por processo de abrasão.

Em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06

Em que pese a tese defensiva, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal. Isso porque o réu Lucas foi surpreendido no momento em que entregava drogas ao usuário que, em sede policial, confirmou que o local é conhecido como ponto de drogas e que, na ocasião, havia acabado de comprar o entorpecente do denunciado (fls. 11).

Como se não bastasse, em poder de Lucas foram apreendidas algumas porções de maconha, as quais estavam igualmente embaladas em comparação àquelas apreendidas no interior da sacola de propriedade de Eric. Ainda, foi apreendida expressiva quantia em dinheiro, em notas diversas, sobre a qual Lucas não soube informar a procedência.

Outrossim, os policiais responsáveis pela apreensão da droga apresentaram versões uníssonas e coerentes entre si. Ambos relataram com precisão o ocorrido no dia dos fatos, inclusive o que motivou a abordagem dos acusados, amparada na atitude suspeita da pessoa de Wanderson, que comprava drogas no local.

Ademais, dúvidas não há acerca da finalidade do entorpecente, a qual é inequívoca no sentido de que se destinava à distribuição para consumo de terceiros.

A propósito, sobre o tema, a palavra de policiais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma evidência de que têm interesse no resultado da demanda penal e desde que esteja em consonância com o conjunto probatório, o que não se verificou no presente caso. Nesse sentido, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas

corpus não conhecido" (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Em sentido contrário, os depoimentos das informantes Devanir e Janaina devem ser analisados com cautela, haja vista se tratar de mãe e amiga de um dos réus, respectivamente. Não há nos autos indícios suficientes a amparar suas versões e afastar os relatos dos policiais responsáveis pela apreensão da droga e do artefato, os quais não possuem qualquer interesse no processo.

Assim, a quantidade de drogas e a forma de acondicionamento, juntamente com toda a circunstância fática que envolveu a prisão dos denunciados (policiais que visualizaram a venda efetiva da droga; depoimento do usuário em sede policial confirmando tais fatos; apreensão de expressiva quantidade de dinheiro, em notas trocadas, sem qualquer comprovação de procedência), permitem concluir que o entorpecente se destinava unicamente ao consumo de terceiros, num comércio ilegal. Friso que o contexto fático não permite afastar tal destinação.

Por outro lado, não se está afirmando que os réus não sejam usuários de drogas, já que é perfeitamente corriqueira a coexistência da figura do usuário-traficante. O que se está concluindo é que, na ocasião, os acusados tinham em depósito entorpecentes que não estavam destinados a seu consumo pessoal, mas sim, ao tráfico ilícito.

Comprovadas, portanto, autoria e materialidade delitiva do delito em tela, passo a dosar a pena dos réus.

Em relação ao réu Eric, na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que ele ostenta maus antecedentes, porquanto a certidão de fls. 65/66 (processo nº 0000366-63.2010) atesta condenação definitiva pelo mesmo crime em apreço, praticado antes destes fatos e com trânsito em julgado posterior, razão pela qual fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ainda, pelo mesmo motivo, fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 16 da Lei 10.826/03.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea tão somente em relação ao delito de porte de arma de fogo, motivo pelo qual retorno a pena ao seu patamar mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

No mais, em relação ao crime de tráfico de drogas, deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea, conforme requerida pela defesa, porque o acusado não confirmou os termos da denúncia, se limitando a reconhecer a propriedade da droga, mas negando a traficância, apresentando versão de desclassificação para consumo pessoal.

Na terceira e derradeira fase, deixo de aplicar a redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, vez que os maus antecedentes e o fato de o réu ter se envolvido com o tráfico de drogas ainda durante sua menoridade demonstram que ele se dedica ao comércio espúrio, não fazendo jus à referida causa de diminuição de pena. O C. STJ já se pronunciou nesse sentido: "(...) é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (...)" (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017);

"(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. (...)". (HC 498.401/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019). "2. Esta Corte já se manifestou no sentido de permitir a utilização

dos maus antecedentes para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria e também para vedar o reconhecimento do tráfico privilegiado, não havendo se falar em bis in idem. Precedentes" (STJ, AgRg no AREsp 942291/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 21-9-2017).

Por fim, presente o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas e, à míngua de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno definitiva em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa.

Em relação ao réu Lucas, na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, vejo que ele é primário, de modo que fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50-0 (quinhentos) dias multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Na terceira e última fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a reprimenda do réu em 2/3, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras.

O regime inicial de cumprimento de pena para o réu Eric será o fechado e para o réu Lucas será o semiaberto medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII). Ademais, o réu Eric é portador de maus antecedentes criminais, demonstrando que vem fazendo da prática delitiva seu modo de vida.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, pois não há nos autos elementos que possam aferir a real situação econômica do sentenciado.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos, especialmente em face da hediondez do ato praticado e dos maus antecedentes do réu Eric.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ERIC FERNANDO SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa, no valor mínimo unitário, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como para CONDENAR o réu LUCAS IVAIR CANDIDO, também qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Por fim, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu LUCAS IVAIR CANDIDO da imputação de ter praticado a conduta prevista no artigo 16 da Lei 10.826/03.

Os réus poderão recorrer em liberdade porque foram soltos durante toda o trâmite processual, não se mostrando necessária, nesse momento, a decretação de sua custódia cautelar.

Autorizo, desde já, a destruição de entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames e decreto a perda em favor da União, dos objetos e valores apreendidos, que serão revertidos diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63 e § 1º, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).

Nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, arcarão os acusados com o pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observando-se o artigo 12, da Lei nº 1.060/50, pois eles são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.

Araçatuba, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA